

身分犯の共犯に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 刑法第65条第1項は、真正身分犯の成立及び科刑について規定し、同条第2項は、不真正身分犯の成立及び科刑について規定していると解する見解に立ちつつ、常習賭博罪における常習性も身分に含まれると解すると、賭博の非常習者甲が賭博の常習者乙を教唆して賭博をさせた場合、乙には常習賭博罪が成立し、甲には同罪の教唆犯が成立する。
2. 刑法第65条について前記1と同様の見解に立ちつつ、事後強盗罪は「窃盗」という身分を有する者だけが法益を侵害し得る身分犯であって、他の犯罪の加重類型ではないと解すると、窃盗犯人甲が、逃走中、追跡してきた被害者乙に対し、逮捕を免れるため、乙の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた際、その事情を知った丙が、甲の暴行行為を幫助した場合、丙が窃盗行為に全く関与していなかったとしても、丙には事後強盗罪の幫助犯が成立し、その刑が科される。
3. 刑法第65条について前記1と同様の見解に立ちつつ、目的犯における目的も身分に含まれると解すると、営利の目的を有する甲が、成人乙を買い受けるに際し、かかる目的を有しない丙がこれを幫助した場合、甲には営利人身買い受け罪が成立し、丙には人身買い受け罪の幫助犯が成立する。
4. 刑法第65条第1項は、真正身分犯及び不真正身分犯を通じて共犯の成立について規定し、同条第2項は不真正身分犯の科刑について規定していると解する見解によれば、財物の非占有者甲が、財物を業務上占有する乙を教唆して当該財物を横領させた場合、甲には業務上横領罪の教唆犯が成立し、単純横領罪の刑が科せられる。
5. 刑法第65条第2項の「身分のない者には通常の刑を科する」の意義について、身分に応じて、加重又は減輕された身分犯が成立すると解する見解によれば、未成年者乙の保護責任者である実母の甲が、保護責任者でない甲の内縁の夫丙を教唆して乙を山中に遺棄させた場合、甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し、丙には単純遺棄罪が成立する。

No168	身分犯の共犯	正答率
H20-15	正 解	66%

身分の作用についての規律を定める65条の解釈について、第1に、文理に忠実に、同条1項は構成的身分の連帯作用を、同条2項は加減的身分の個別作用を定めているとする見解がある（大判大2.3.18、最判昭31.5.24等、肢1～3）。第2に、同条1項は構成的身分犯及び加減的身分犯を通じて身分犯における共犯の成立について規定したものであり、同条2項は、特に加減的身分犯については刑の個別作用を定めたものとする見解がある（肢4）。第3に、身分を行為の違法性に関係する身分（違法身分）と責任に関係する身分（責任身分）とに分け、同条1項は違法身分の連帯作用を定めたものとし、同条2項は責任身分の個別作用を定めたものとする見解がある。

1 誤っている

肢1の見解によれば、乙は常習性という身分を有するため、乙に常習賭博罪（186条1項）が成立する。他方、甲は「賭博」を教唆しているものの、常習性を有しない。常習賭博罪は、単純賭博罪（185条）の加重類型であり、不真正身分犯といえるため、65条2項により、甲に単純賭博罪の教唆犯（61条1項）が成立する。

2 正しい

甲には事後強盗罪（238条）が成立する。肢2は事後強盗罪を真正身分犯と解しているから、窃盗犯人たる身分を有しない丙には、65条1項により、事後強盗罪の幫助犯（62条1項）が成立し、その刑が科される。

3 正しい

肢3の見解によれば、甲は営利目的という身分を有するため、甲には営利目的人身買受け罪（226条の2第3項）が成立する。他方、丙は営利の目的を有しない。営利目的人身買受け罪は、人身買受け罪（同条1項）の加重類型であり、不真正身分犯といえるため、65条2項により、丙には人身買受け罪の幫助犯が成立する。

4 正しい

乙には業務上横領罪（253条）が成立する。肢4の見解によれば、65条1項により、甲に業務上横領罪の教唆犯が成立する。業務上横領罪は、占有者という点では真正身分犯であるが、業務者という点では不真正身分犯であるから、同条2項により、業務者たる身分を有しない甲には単純横領罪（252条1項）の刑が科せられる。

5 正しい

丙は保護責任者という身分を有していないため、丙には単純遺棄罪（217条）が成立する。他方、保護責任者遺棄罪（218条）は単純遺棄罪の加重類型であるから、肢5の見解によれば、65条2項により、保護責任者という身分を有している甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立する。